

罪数に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、夜間、車道上にロープを張って、車道を閉塞したところ、自動二輪車を運転して同所を通り掛かった乙がこれに気付かないまま同ロープに引っ掛かり、転倒して負傷した。この場合、甲に乙が負傷をすることについて故意があれば、甲には往来妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は牽連犯となる。
2. 甲は、乙を殺害する目的で乙方に侵入し、屋内にいた乙を殺害した上、たまたま屋内に居合わせた丙及び丁も殺害した。この場合、甲には、住居侵入罪並びに乙、丙及び丁に対する殺人罪が成立し、住居侵入罪と乙に対する殺人罪が牽連犯として一罪となり、丙及び丁に対する殺人罪と併合罪になる。
3. 甲は、眼鏡を掛けた乙の顔面を、眼鏡の上から拳で殴打し、眼鏡を損壊するとともに、乙に全治1週間を要する顔面打撲の傷害を負わせた。この場合、甲には傷害罪と器物損壊罪が成立し、両罪は併合罪となる。
4. 甲は、真実は、自己の経営する会社の運転資金に使う目的で、質権を設定するつもりもないのに、乙に対して、「2000万円をA銀行の甲名義預金口座に振り込んでほしい。振り込まれた2000万円については、見せ金として使用するので、口座から引き出さないし、振込み後、質権も設定する。」などと嘘を言い、これを信じた乙は、A銀行の甲名義預金口座に2000万円を振り込んだ。その数日後、甲は、同預金に関するA銀行名義の質権設定承諾書1通を偽造し、乙に交付した。この場合、甲には詐欺罪、有印私文書偽造及び同行使罪が成立し、これらは牽連犯として一罪となる。
5. 甲は、乙を監禁した上で現金を恐喝しようと企て、乙をマンションの一室に監禁し、暴行・脅迫を加えて現金を脅し取った。この場合、甲には監禁罪と恐喝罪が成立し、両罪は併合罪となる。

№190	罪 数	正答率
H23-6	正 解 5	75%

1 誤っている

甲は、車道上にロープを張って、車道を閉塞しているから、往来妨害罪（124条1項）が成立する。往来妨害致傷罪は、往来妨害罪の結果的加重犯であるから、人の傷害の結果につき故意のあることを要せず、また故意のない場合でなければならない。故意があった場合には、往来妨害罪と傷害罪が成立するとされている。甲に乙が負傷することにつき故意がある本記述では、往来妨害致傷罪は成立せず、往来妨害罪と傷害罪が成立する。そして、甲の行った閉塞行為という1個の行為が、往来妨害罪及び傷害罪という2個以上の罪名に触れる場合であるから、両罪は観念的競合（54条1項前段）となる。

2 誤っている

最決昭29.5.27（百選I106事件）は、「所論3個の殺人の所為は所論1個の住居侵入の所為とそれぞれ牽連犯の係にあり刑法54条1項後段、10条を適用し一罪としてその最も重き罪の刑に従い処断すべきであ」とする。本来併合罪の係にある複数の罪が、各々と科刑上一罪の係にある共通の他の罪を媒介として全体として一罪となるとする考え方を、「かすがい理論」と呼ぶ。よって、乙、丙及び丁に対する3個の殺人罪が成立し、それぞれ1個の住居侵入罪と牽連犯となり、全体として一罪となる。

3 誤っている

1個の行為により複数の法益侵害を惹起したが、主たる法益侵害に付随して惹起された従たる法益侵害は、独立して別途処罰の対象とするまでもなく、主たる法益侵害を処罰の対象とする罪の法定刑の枠内においてすでに情状として併せ考慮されていると考えることができるから、主たる法益侵害惹起を処罰の対象とする罪の刑に従たる法益侵害を処罰する罪を吸収評価し、主たる法益侵害を処罰の対象とする罪の罰条のみを適用すれば足りると解されている。そして、裁判例は、眼鏡の損壊は、顔面を手拳で殴打して傷害を負わせるという通常の行為態様による傷害に随伴するものと評価することができることなどから、器物損壊罪と傷害罪は観念的競合の係を認める必要はなく、傷害によって包括的に評価されるとしている（東京地判平7.1.31）。

4 誤っている

東京高判平7.3.14は、詐欺罪、有印私文書偽造罪及び同行使罪が成立する場合は牽連犯となるが（大判明42.1.22）、金銭を詐取した後に偽造の質権設定承諾書を交付するような本記述と同様の事案では、重い詐欺の包括一罪が成立するとしている。

5 正しい

最判平17.4.14（百選I103事件）は、「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても、両罪は、……牽連犯の係にはない」として、これらを併合罪として処断した第1審判決を是認した原判決を維持している。その理由として、判例は、「両罪は、犯罪の通常形態として手段又は結果の係にあるものとは認められ」とないということを挙げている。よって、本記述において、甲には監禁罪と恐喝罪が成立し、両罪は併合罪となる。